

1501642-58.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501642-58.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501642-58.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2227705/2021 - DEL.POL.ITAPEVI, 19764530 - DEL.POL.ITAPEVI, 2333/21/407 - DEL.POL.ITAPEVI, 2227705 - DEL.POL.ITAPEVI, 2333/2021 - Delegacia de Polícia de Itapevi, 2227705/2021 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO HENRIQUE SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

RODRIGO HENRIQUE SILVA, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Alfa, n.º 100, CDHU Vila Gioia, nesta cidade e Comarca de Itapevi, o réu guardava e tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (f. 96) e apresentou defesa prévia (f. 101-109).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 20 de janeiro de 2022, na qual também foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa (f. 120-123).

O réu foi citado, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 137). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações

finais (f. 137).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

A confissão, aliás, restou corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 11, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse do acusado.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a laudo de constatação (f. 17-20 e 21-23), sendo que os materiais foram analisados pelo teste colorimétrico cujos resultados foram positivos para cocaína em material sólido particulado ("cocaína") e petrificado ("crack"), para tetrahydrocannabinol (componente ativo da "maconha") e para cloreto de metileno, drogas de uso proscrito no Brasil.

Importante ressaltar que, conquanto não se tenha juntado laudo definitivo nos autos, a materialidade do crime restou suficientemente demonstrada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

O laudo de constatação foi devidamente assinado por perito criminal (f. 20 e 23), tendo sido realizado teste colorimétrico que atestou a existência das substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos em posse do acusado.

O caso se enquadra à hipótese excepcionada pelo C. STJ, que entendeu, no julgamento do HC n.º 605.603/ES, que, à míngua de laudo definitivo que comprove a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, outros elementos probatórios suprem a sua ausência, como o auto de constatação, testemunhas e o laudo preliminar, desde que elaborado por perito oficial e em procedimento equivalente ao do definitivo. Veja-se excerto da ementa:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA AOS CORRÉUS.

1. Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, como na hipótese.

(...)

(STJ, HC n.º 605.603/ES, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/03/2021)

Também o E. TJSP tem decidido nesse sentido:

Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, 'caput' e 35, 'caput', ambos da Lei nº 11.343/06) – Preliminar de nulidade do processo por ausência de materialidade,

em face da não juntada do laudo toxicológico aos autos - Inocorrência - Materialidade delitiva demonstrada por meio do laudo de constatação - A falta de apresentação de laudo definitivo, por si só, não inquina de nulidade o título penal condenatório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - No mérito, pedidos de absolvição, em relação a ambos os delitos, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de aplicação do redutor de penas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e impondo-se regime menos gravoso para o seu eventual cumprimento; e, ainda, de afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, do mesmo diploma legal - Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento - Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos - Ação revisional julgada improcedente. (TJSP, Revisão Criminal n.º 2268514-89.2020.8.26.0000, 4º Grupo de Direito Criminal, Rel. Otávio Rocha, julgado em 06/04/2021)

Suficientemente demonstrada, pois, a materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Quanto à autoria, tem-se que a policial militar, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relata que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico, quando avistou o réu que tentou se evadir quando viu a viatura da polícia. Ele estava em posse de uma sacola e se livrou dela ao fugir, abrigando-se em uma casa. Recuperada a sacola, havia drogas em seu interior. Abordou o acusado dentro da residência onde ele adentrou e também lá havia drogas.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria da policial de incriminar injustamente o acusado. Assim, seu depoimento merece credibilidade e é valioso para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas no depoimento da policial militar, permitem presumir que as drogas apreendidas com o acusado se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

Mesmo porque a quantidade de drogas encontrada é incompatível com o mero uso próprio, a variedade era ampla (três tipos de entorpecentes) e o próprio réu afirmou que estava armazenando as substâncias para o tráfico.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à aplicação da circunstância privilegiadora, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, revendo posicionamento anterior e tendo em vista os recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, não vislumbro inconstitucionalidade na incidência da causa de diminuição de pena.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação da privilegiadora ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, o réu, embora seja primário e possua bons antecedentes, não preenche o último requisito, já que restou demonstrado nos autos que se dedica a atividades criminosas.

Ora, o acusado afirmou, em seu interrogatório, que armazenava em sua residência drogas destinadas ao tráfico e que o fazia pela terceira vez quando foi preso em flagrante delito.

O tráfico não era, pois, praticado pelo réu de forma eventual e esporádica, mas rotineiramente, numa estrutura para o crime (já que armazenava as substâncias para que outras pessoas realizassem a mercancia) - o que caracteriza sua dedicação ao crime.

Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, com vontade e consciência, trazia consigo e guardava as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, já qualificado, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial - inclusive para a aferição

de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente -, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: "O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo - mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais" (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP - "personalidade e conduta social do agente". Outrossim, tem-se que "a natureza e a quantidade da substância ou produto" podem ser analisadas no contexto das "circunstâncias" do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da "preponderância" prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima - personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena - ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o réu não ostenta antecedentes criminais.

Por outro lado, as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao denunciado, tendo em vista que estava na posse de quantidade considerável de entorpecentes (1,63kg de maconha, 288,59g de cocaína, 601,66g de crack e 6920ml de lança-perfume - f. 17-23), valendo destacar as naturezas diversas das substâncias apreendidas - maconha, lança-perfume, cocaína e crack (de baixo, alto e altíssimo poder destrutivo).

Nesse contexto, havendo uma circunstância judicial preponderante negativa, fixo a pena base em 06 anos e 10 meses de reclusão - e 683 dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante da menoridade relativa para ser considerada, nos termos do art. 65, I, do CP, tendo em vista que acusado era menor de 21 anos de

idade na data dos fatos (f. 05).

Incide, outrossim, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), de modo que a pena devia ser reduzida em 1/3, sendo 1/6 referente a cada atenuante. Contudo, tendo em vista o enunciado da súmula n.º 231 do STJ, do qual se comunga entendimento, fixo a pena, provisoriamente, em 05 anos de reclusão - e 500 dias-multa.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo a reprimenda, agora definitivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão - e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais.

Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra. Expeça-se a guia de execução provisória.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA